

1501921-34.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... INCLUSIVE, ELE JÁ FOI PRESO POR TRÁFICO DE DROGA". Em juízo confirmou sua versão. Acrescentou que o réu já foi abordado em várias outras ocasiões em situação suspeita, mas nada com ele foi abordado. Ele estava indo em direção ao recuo do muro e quando ele viu a viatura, ele mudou de direção. Todo dia tem ocorrência de tráfico no local. O réu admitiu informalmente que vendia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501921-34.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2342732/2021 - 05º D.P. PIRACICABA, 21990672 - 05º D.P. PIRACICABA, 1436/21/528 - 05º D.P. PIRACICABA, 2342732 - 05º D.P. PIRACICABA, 2342732/2021 - 05º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO FESSEL

Réu Preso

Contr. nº 2021/001320

Aos 07 de março de 2022, às 16:20 horas, por meio de audiência virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Antonio Carlos Perez Antunes da Silva foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu FERNANDO FESSEL (preso nosso CDP local). Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PMs Flavio Zanoni Junior e WANDERSON ELIAS RAMOS DA COSTA AZEVEDO

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

Pela M.M Juíza de Direito foi explicado que, diante da restrição de acesso ao prédio do Tribunal de Justiça, em razão da pandemia do COVID-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e orientação do Comunicado CG nº 284/2020, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft.

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não

terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (Pms Bruno e Wanderson) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a).FERNANDO FESSEL, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 10h00min, na Rua Raul Ataíde, nº 165, Bairro Boa Esperança, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, para fins de tráfico, trazia consigo e guardava, 2,2g de Cannabis sativa L. distribuídos em 02 invólucros, 0,2g de cocaína na forma de pedra, distribuídos em 02 invólucros, 27,7g de Cannabis sativa L. distribuídos em 25 invólucros e 3,8g de cocaína na forma de pedra, distribuídos em 45 invólucros, substâncias entorpecentes as quais determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (fls. 81/84). O réu foi notificado, a denúncia foi recebida e durante a instrução prestaram depoimento as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o réu interrogado. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade delitiva foi confirmada nos autos pelo auto de exibição e apreensão a fl. 11, fotos a fl. 12 e laudos a fls. 113/115. Da mesma forma, comprovada a autoria delitiva. De fato, o policial relatou, na fase informativa (fls. 04), que "ESTAVA COM MEU COMPANHEIRO FLAVIO, REALIZANDO PATRULHAMENTO PELAS PROXIMIDADES DO LOCAL DOS FATOS, AMBOS COM MOTOCICLETAS (ROCAM), QUANDO AVISTAMOS O INDICIADO, EM LOCAL DE PONTO DE VENDA DEDROGA; ELE CAMINHAVA EM DIREÇÃO AO RECUO DE UM MURO, NAS PROXIMIDADES, SENDO QUE AO VER AS MOTOS DA EQUIPE, O MESMO MUDOU DE DIREÇÃO PARA TENTAR SE LIVRAR DA ABORDAGEM, MAS NÃO FOI POSSÍVEL, POIS, ACABAMOS POR DETÊ-LO; EM REVISTA PESSOAL, COM O INDICIADO, FORAM LOCALIZADAS 02 "PARANGAS" DE MACONHA, 02 "PEDRINHAS" DE CRACK E 10 REAIS EM DINHEIRO, DUAS NOTAS DE CINCO REAIS; FOI NECESSÁRIA O USO DE FORÇA FÍSICA, POIS, O INDICIADO NÃO QUERIA SER PRESO, INCLUSIVE, TIVEMOS QUE UTILIZAR ALGEMAS, PARA NOSSA SEGURANÇA; APÓS O INDICIADO SER DETIDO, EU FUI ATÉ O RECUO DO MURO, PARA ONDE O INDICIADO ESTAVA indo, SENDO QUE LÁ, ACABEI ENCONTRANDO MAIS 25 "PARANGAS" DE MACONHA E MAIS 45 "PEDRINHAS" DE CRACK, TODAS EMBALAGENS IGUAIS AS QUE ENCONTRAMOS COM O INDICIADO; DIANTE DOS FATOS, COMO AUTORIDADE POLICIAL MILITAR, DEI VOZ DE PRISÃO AO INDICIADO, SENDO QUE FOI LEVADO ATÉ O PRONTO SOCORRO E DEPOIS TRAZIDO ATÉ ESTA UNIDADE, ONDE A AUTORIDADE LAVROU O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONTRA O INDICIADO; CONHEÇO O INDICIADO DE OUTRAS ABORDAGENS, INCLUSIVE, ELE JÁ FOI PRESO POR TRÁFICO DE DROGA". Em juízo confirmou sua versão. Acrescentou que o réu já foi abordado em várias outras ocasiões em situação suspeita, mas nada com ele foi abordado. Ele estava indo em direção ao recuo do muro e quando ele viu a viatura, ele mudou de direção. Todo dia tem ocorrência de tráfico no local. O réu admitiu informalmente que vendia drogas para poder manter o seu vício. O réu estava fazendo menção de ir naquele local, o que originou o motivo da abordagem. Por sua vez, o seu companheiro de farda confirmou os fatos relatados por seu companheiro de farda. Assim, a grande quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, juntamente com a apreensão de dinheiro, somadas às circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam o comércio ilícito. De fato, na posse do réu foram encontradas porções de maconha, de crack e de dinheiro. Ademais, ele fazia menção a acessar um recuo de um muro, onde foram encontradas dezenas de drogas idênticas. Ainda, o acusado confessou informalmente a prática delitiva. Como se não bastasse isso, o local é ponto de venda de drogas e o acusado já havia sido abordado anteriormente em atitude suspeita no mesmo local e é reincidente específico. Neste panorama, devidamente demonstrada materialidade e autoria delitivas. Diante do acima exposto, requer-se a procedência da ação,

condenando-se o réu nos termos da incoativa. Na aplicação da pena há que se observar que o réu é reincidente específico (certidão a fls. 45/46), razão pela qual não faz jus à causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Outrossim, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, de acordo com as normas legais, e porque o crime de tráfico merece um grau maior de reprovabilidade, pois causa sérias consequências no meio social, notadamente no meio familiar, fomentando o uso indiscriminado de entorpecentes e, consequentemente, a prática de outros crimes pelo usuário, como pequenos furtos e roubos, os quais são praticados com o escopo de sustentar o seu vício. Incabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que reconhecida a impossibilidade de ser aplicado o redutor pelas razões antes mencionadas, a pena suplantará 04 anos, bem como o crime em questão é de elevada gravidade, o que demonstra não ser a medida socialmente adequada. Por fim, uma vez que comprovado que o dinheiro apreendido era oriundo do comércio de drogas, o Órgão Ministerial requer que seja decretada sua perda.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). FERNANDO FESSEL foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme os fatos narrados na inicial acusatória. Recebida a denúncia, o feito teve seu regular trâmite, sendo encerrada a instrução na presente audiência. O Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Ocorre, contudo, que a ação penal deve ser julgada improcedente. Excelência, inicialmente é preciso reconhecer que não há provas que permitam concluir, com segurança, que o réu incorreu no crime de tráfico de entorpecentes que lhe foi atribuído. Na fase policial, por ocasião de seu interrogatório, o acusado negou a prática delitiva, afirmando que após visitar a filha, parou na casa de um amigo, que lhe tinha oferecido um emprego de vender pães. Quando o chamava, apareceram dois garotos que pararam ao seu lado. Na sequência, policiais militares da ROCAM surgiram ali e abordaram todos. Os policiais encontraram drogas e liberaram os menores. Disse que os policiais disseram que as drogas lhe pertenciam. Foi agredido pelo policial militar Azevedo. Alegou ser morador de rua e usuário de crack, porém não estava traficando. Judicialmente, o réu renovou a negativa. Alegou que não tinha nada consigo e que já foi abordado em outras ocasiões pelos policiais que pediam informações sobre tráfico. Disse que não podia falar quem vendia drogas no local. Afirmou que estava em situação de rua. Negou ter confessado o tráfico aos policiais, os quais o abordam constantemente. Ainda durante a persecução penal foram ouvidos dois policiais militares responsáveis pela prisão do réu, Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo e Flavio Zanoni. Na fase policial, ambos declararam que efetuavam patrulhamento pelo local dos fatos quando viram o réu caminhando em direção ao recuso de um muro. Porém, quando ele percebeu a presença das motos, ele mudou de direção, acabando, então, abordado. Ele resistiu e foi necessário o uso de força moderada. Em seu poder acabaram localizando duas porções de maconha, duas porções de crack e dez reais em dinheiro. No recuso do muro, encontraram mais vinte e cinco porções de maconha e outras trinta e cinco porções de crack, embaladas de forma idêntica àquelas que estavam em poder dele. Disseram ainda que ele era conhecido dos meios policiais. Sob o pálio do contraditório, o policial Azevedo disse que patrulhavam pelo local, que era conhecido pelo tráfico, quando viram o réu se dirigindo em direção a um muro. Como ele mudou de trajeto, decidiram abordá-lo. Ele estava com drogas e no local para onde se dirigia, encontraram um saco contendo mais drogas. Esclareceu que tinha duas porções de maconha e duas porções de crack com o réu. No muro estavam vinte e cinco porções de maconha e quarenta e cinco pedras de crack. Réu alegou que era usuário e que vendia para sustentar o vício. Relatou que já conhecia o réu de outras abordagens realizadas nas proximidades. Relatou ainda que não chegaram a ver o réu mexendo no muro, e que ele estava próximo. Afirmou que o local era conhecido e todo dia tem denúncia. No dia dos fatos, mais pessoas estavam por ali. Já Flávio Zanoni disse que o réu fingiu que estava conversando antes de ser abordado. Alegou que no calor do momento o acusado acabou dizendo que vendia droga para sustentar o vício. Disse que no local há alta incidência de tráfico e que outras pessoas estavam por ali. Disse que também realizou outras abordagens no acusado naquele local. Ou seja, como se

nota, a versão exculpatória do acusado não foi afastada pelas demais provas produzidas, na medida em que só foram ouvidos os responsáveis pela sua prisão que, evidentemente, são testemunhas parciais. Afinal, não há como negar que os depoimentos dos policiais militares estão contaminados pela atuação que tiveram na apuração dos fatos, o que gera a necessidade de justificar os atos praticados. Assim, ainda que não estejam impedidos de depor, certo é que seus testemunhos devem ser recebidos com cautela, sobretudo no momento de se conferir o devido valor probatório. Não é por outra razão que em diversas ocasiões já se decidiu pela impossibilidade de se fundamentar uma condenação apenas com base na palavra dos responsáveis pela persecução penal: "As palavras dos policiais merecem credibilidade, mas não basta o título (exercício da função de policial). Há necessidade de que estas tenham apoio em evidências circunstanciais e testemunhais, sob pena de exaltar-se um registro indiciário como absoluto, infalível e inquestionável". (TJSP - 7ª Câ. - Ap. Cr. n. 1.465.651/6 - Com. de Campinas - j. 19/5/2005 - v.u.). No mesmo trilho ensina o professor Gustavo Henrique Badaró (os destaques são nossos): "Quanto aos depoimentos dos policiais, há correntes radicais, que, pelo seu próprio extremismo, devem ser descartadas. Uma dessas correntes entende que o fato de a testemunha ser policial, por si só, não a torna impedida de depor, não havendo qualquer disposição legal neste sentido. Ao contrário, o policial não se enquadra nas hipóteses do art. 207 do CPP, devendo ser dado ao seu depoimento o mesmo valor de qualquer outra testemunha. De outro lado, há corrente oposta, no sentido de que os policiais, pela simples condição funcional, seriam suspeitos. Deve prevalecer uma corrente intermediária: se os policiais não podem ser considerados suspeitos, pelo simples fato de serem policiais, por outro lado, é inegável o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos investigatórios praticados, pelo que seus depoimentos têm valor relativo, devendo ser cotejados com outros elementos de provas existentes nos autos, em especial o testemunho de pessoas estranha aos quadros da polícia. Não se pode esquecer que as testemunhas são, por definição, terceiros imparciais, sem qualquer interesse no processo, o que não é exatamente o caso dos policiais em relação aos crimes por eles investigados. Por tais motivos, não se deve admitir que seja proferida uma sentença condenatória com base exclusiva no depoimento de policiais, ainda que estes se mostrem harmônicos entre si". (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 8ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 588). E, no caso sob análise, para além dos depoimentos dos agentes integrantes aos quadros da segurança pública, nenhuma outra prova foi produzida. Assim, as provas produzidas contra o réu são bem precárias, ainda mais considerando o crime que lhe é atribuído, equiparado a hediondo. Não se quer dizer que os policiais mentiram, mas apenas que para a condenação prova mais robusta é necessária. A propósito, cumpre registrar que quanto mais se dá crédito a esse tipo de prova, mais se incentiva a precariedade de investigações, o que pode dar azo a abusos e manipulações. Dessa forma, por tudo que foi exposto, sendo frágil o conjunto probatório, a Defesa requer a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP. De maneira subsidiária, requer-se a desclassificação da conduta do acusado para a prevista no art. 28, da Lei de Drogas, uma vez que com ele, efetivamente, só foram encontradas poucas porções de drogas. As demais, segundo consta, estavam em local aberto e acessível a qualquer pessoa, de sorte que não necessariamente pertenciam ao réu, que também se declarou usuário, tendo passado por diversas internações. Assim, remanescendo um cenário duvidoso quanto à propriedade das demais drogas, de rigor a desclassificação para o crime de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Todavia, caso o entendimento de Vossa Excelência seja diverso, em caso de condenação pelo crime mais grave narrado na denúncia, requer-se a fixação da pena no mínimo legal, considerando que não houve apreensão significativa de entorpecente. Também é o caso de aplicação da causa redutora de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, inobstante a condição de reincidente do réu. Isso porque essa circunstância será considerada para agravar a pena do réu na segunda etapa. Assim, sua utilização para negar a diminuição da pena acaba constituindo bis in idem, não autorizado pelo ordenamento jurídico, que rechaça a possibilidade da mesma

circunstância ser utilizada por mais de uma vez para agravar a situação do agente. Além disso, o STJ já decidiu que a reincidência, por si só, não afasta o "tráfico privilegiado": "A ínfima quantidade da droga apreendida não justifica o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo perfeitamente cabível a sua aplicação em patamar intermediário (1/2), diante da reincidência" (HC 660.930/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021). Dessa forma, nada impede que seja reduzida a pena do réu, ainda que não seja no patamar máximo. E com o reconhecimento da causa especial de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, mostra-se possível, por consequência, a fixação de regime inicial diverso do fechado. Por fim, tendo em vista o princípio da presunção de inocência, requer-se seja conferido ao acusado o direito de apresentar eventual apelação em liberdade.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos.

FERNANDO FESSEL, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 10,00 horas, na Rua Raul Ataíde nº 165, Bairro Boa Esperança, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, para fins de tráfico, trazia consigo e guardava, 2,2g de Cannabis sativa L. distribuídos em 02 invólucros, 0,2g de cocaína na forma de pedra, distribuídos em 02 invólucros, 27,7g de Cannabis sativa L., distribuídos em 25 invólucros, e 3,8g de cocaína na forma de pedra, distribuídos em 45 invólucros, substâncias entorpecentes as quais determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares realizavam diligências no sobredito local, ocasião em que avistaram o acusado em atitude suspeita, caminhando sentido ao recuo de um muro, mas ao notar a aproximação dos policiais, tentou se evadir e foi abordado. Em sua posse localizaram 02 invólucros de maconha, 02 de "crack" e a quantia de R\$10,00, proveniente do narcotráfico. Na sequência, realizaram buscas no recuo do referido muro e encontraram mais 25 invólucros de maconha e 45 pedras de "crack", embaladas de maneira idênticas àquelas drogas encontradas na posse do réu. Conclui a denúncia que todas as drogas pertenciam ao acusado e que se destinavam à mercancia ilícita.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 105). Defesa preliminar apresentada às fls. 109/110. Após, a denúncia foi recebida (fls. 111) e o réu foi citado às fls. 145.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade do delito.

A Defesa pediu a absolvição, por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) Boletim de ocorrência de fls. 08/10;
- 2) Auto de exibição e apreensão de fls. 11/13; e
- 3) Laudo de constatação de fls. 19/25 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 92/98, com resultado positivo para tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 06), o réu negou o crime. Declarou que foi visitar sua filha, de sete anos de idade e, ao retornar, parou na casa de um amigo que havia lhe oferecido um emprego de vender pães. Quando começou a chamá-lo, foi surpreendido por dois garotos que corriam e pararam ao seu lado. Em seguida, policiais militares da ROCAM apareceram e os abordaram, liberando apenas os menores. Os policiais disseram que encontraram drogas em sua posse, mas negou o

fato. Eles persistiram na afirmação e, inclusive, um deles, o policial Azevedo, o agrediu, causando escoriações em seus antebraços e dor forte no pescoço. Afirmou que era usuário de "crack" e que estava em situação de morador rua, porém não portava entorpecente. Por fim, disse que desconhecia as drogas apresentadas pelos policiais na delegacia.

Interrogado em juízo (gravação), novamente negou o crime, repetindo que é morador de rua e, no dia dos fatos, foi visitar a filha. Após, parou na frente da casa de um rapaz que o ajudava com roupas e iria lhe oferecer um trabalho. Ali foi abordado pelos policiais junto com dois rapazes que se aproximaram. Eles o acusaram injustamente de tráfico. Disse que não era a primeira vez que o abordavam. Todas as vezes que o pegavam nas redondezas desse mesmo local, que é conhecido como ponto de tráfico, os policiais sempre exigiam que lhes dissesse quem era o traficante que atuava naquele ponto e falavam que, um dia, seria preso.

A negativa do réu foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 04) e em juízo (gravação), o policial militar Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo declarou que estava em patrulhamento com seu companheiro de farda, PM Flávio, no bairro Boa Esperança, quando avistaram o réu no local dos fatos dirigindo-se ao recuo de um muro e, quando estava muito próximo desse ponto, ele notou a aproximação da polícia e imediatamente mudou de direção. Diante de sua atitude suspeita, resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, localizaram com ele 02 porções de maconha, 02 pedras de "crack" e R\$ 10,00 em dinheiro. No recuo do muro para onde viram o acusado se dirigindo encontraram mais 25 porções de maconha e 45 pedras de "crack", embaladas da mesma forma que aquelas encontradas com o réu. Disse que já o conhecia de outras abordagens por suspeita de tráfico. O local era muito conhecido como ponto de tráfico e os traficantes costumavam esconder as drogas em recuos das construções. O réu admitiu que estava traficando e falou que fazia isso para sustentar o vício de drogas. Não soube dizer se o réu era morador de rua. O local era uma comunidade e, como sempre, havia diversas pessoas na rua. Declarou, por fim, que foi necessário uso de algemas, pois o réu ofereceu resistência.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 05) e em juízo pelo policial militar Flavio Zanoni Junior.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Embora o réu tenha alegado que já sofreu outras abordagens pelos mesmos policiais desse processo, também admitiu que elas não resultaram em sua prisão, de modo não há nenhum elemento que indique que os policiais que atuaram no caso em comento mentiram, acusando-o de um crime que não cometeu. Fosse isso verdade, eles já o teriam prendido anteriormente, nas outras abordagens. Não foi o que ocorreu. Os próprios policiais disseram que embora já tivessem abordado o réu nas proximidades do local dos fatos por suspeita de tráfico, não o haviam detido porque nunca haviam encontrado drogas relacionadas a ele.

No mais, presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao

recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressaltados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos policiais militares: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia consigo e guardava as drogas descritas na denúncia para fins de mercancia.

De fato, sua negativa foi afastada pelos uníssonos e convergentes depoimentos dos policiais militares no sentido de que as substâncias entorpecentes foram apreendidas na posse do acusado e escondidas no recuo de um muro, para o qual ele se dirigia quando se aproximaram.

Confirma a prática delitativa o fato de o réu ter agido de forma suspeita ao avistar

a presença policial, mudando imediatamente de direção e tentando evitar a abordagem.

As drogas que o réu portava e as que estavam no muro estavam embaladas de forma idêntica, o que confirma estarem todas na posse dele.

Além disso, com o acusado, além dos dois tipos de entorpecentes, foi apreendida a quantia de R\$ 10,00 em notas trocadas, cuja origem lícita não foi comprovada, o que indica que ele estava traficando no local.

Por fim, a quantidade e diversidade de drogas relacionadas ao réu era incompatível com a situação de mero usuário.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas – Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.” (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

“MATERIALIDADE – Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA – Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor – Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' – Validade – Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO – Destinação a terceiros – Quantidade incomum com a figura do usuário – Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo – Apreensão de dinheiro – Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal – Denúncia – De rigor a condenação da ré – Absolvição – Impossibilidade – Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO – Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral – Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA – Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal – natureza da droga de alto potencial lesivo – Manutenção – Presente a atenuante da menoridade – Redução da pena ao mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente – Exasperação da pena em 1/6 – Reconhecido o redutor na fração de 2/3 – Manutenção ante a inércia ministerial – Dedicção da ré à atividade criminosa – Passagem por ato infracional – Apreensão de considerável quantidade de droga – Profissionalização – Dedicção à atividade criminosa – Manutenção porque vedado a reformatio in pejus – Redução da pena – Impossibilidade – Improvimento ao apelo. REGIME – Fechado – Apreensão de elevada quantidade de droga – Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo – Alta reprovabilidade e periculosidade – Ré que ostenta processo por ato infracional – O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) – Regime fechado – Necessidade – Improvimento ao apelo”. (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, ficando afastada a tese defensiva de insuficiência

probatória.

Passo à individualização das penas.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis, razão pela qual fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Reconheço a agravante da reincidência (processo criminal nº 1500202-51.2020, fls. 45/46), o que enseja o aumento da reprimenda em 1/6, perfazendo cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Inexistem atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de penas.

Registro que, por expressa disposição legal, a reincidência impede a aplicação do redutor do parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06 e, tratando-se, inclusive de reincidência específica, impõe a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis (esses também incabíveis em razão da quantidade de pena), pois indica que o réu vem reiterando na prática do crime em questão.

Acrescente-se a isso as graves consequências do delito de tráfico, que fomenta a prática de vários outros crimes, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que dificilmente conseguem se livrar do vício.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seu grave ato.

Há várias decisões de nossos Tribunais no sentido de que é possível a eleição do regime fechado, sem substituição por restritivas de direitos, no crime de tráfico de drogas se a natureza, a reincidência e as circunstâncias concretas do crime indicarem tratar-se de agente de maior periculosidade.

Confira-se julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa - Absolvição por falta de provas - Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares bastam para a comprovação da mercancia ilícita - Tráfico bem caracterizado - Condenação mantida - Penas bem dosadas - Regime inicial fechado bem imposto, diante da gravidade concreta da infração penal e da reincidência específica do réu - Recurso defensivo improvido." (TJSP - Apelação 0037058-28.2016.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Apreensão de 200g de cocaína e um revólver calibre 32. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Incabível a absolvição ou desclassificação. Materialidade e autoria indúvidas. Réu detido na posse de chave de veículo automotor, em cujo interior foram encontradas a arma e as drogas. Ausência de justificativa plausível acerca dos fatos. Forma de acondicionamento do entorpecente aponta a traficância. Porte de arma e munições é delito de perigo abstrato. Arma periciada. Potencialidade lesiva atestada. Dosimetria bem realizada. Reincidência impede a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos. Regime fechado decorre do quantum da pena e da biografia penal do acusado, além da gravidade, consequências e hediondez do crime. Recurso não provido". (TJSP - Apelação 0003463-89.2015.8.26.0400. 8ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator(a): Carlos Monnerat - j. 05/09/2017) -g.n.

"Apelação Criminal. Tráfico. Apreensão de 312 gramas de maconha, no interior de estabelecimento prisional. Recurso defensivo. Pleitos de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da imputação para a rubrica do artigo 28, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Materialidade, autoria, culpabilidade e destinação mercantil, demonstradas pelo acervo coligido - Depoimentos de agentes de segurança penitenciária, seguros e sem contradições, cujo teor foi corroborado pela confissão judicial - Crime caracterizado que afasta a pretensão desclassificatória - Condição de usuária (sequer aventada pela ré) que não impede a prática do tráfico ilícito nem é suficiente para descaracterizá-lo - Majorante configurada (crime perpetrado nas dependências de estabelecimento prisional) - Dosimetria - Reincidência (específica) e gravidade concreta do delito

que obstam a aplicação do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, e impõem o regime prisional fechado para o início da expiação - Condenação confirmada em 2º grau que exige a imediata expedição de mandado de prisão para o início da expiação - Precedente do STF (HC/SP nº 126.292) - Apelo defensivo, não provido, com determinação." (TJSP - Apelação 0016048-25.2016.8.26.0050. 5ª Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Juvenal Duarte - j. 31/08/2017) -g.n.
Registro que o reconhecimento da reincidência para fins de impedir a concessão de benefícios ao acusado e apená-lo de forma mais grave não fere a coisa julgada, nem constitui "bis in idem", pois não se trata de punir o agente duas vezes pelo mesmo fato.

Como bem ensina Guilherme de Souza Nucci, essa ideia "peca pela simplicidade. O sistema de fixação de penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF)" (CP Comentado - RT, 13ª ed., pag. 464).

Ao se reconhecer a reincidência e aumentar a pena do crime em razão dessa agravante ou deixar de aplicar ao réu alguma benesse, o Estado nada mais faz do que punir com maior rigor o agente que, tonando a delinquir, desafia a ordem pública e as leis vigentes, demonstrando, no dizer do professor Nucci, "persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade. Destarte, sofre uma punição mais severa" (obra citada, pag. 464).

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico.

APELAÇÃO CRIMINAL - PENA E REGIME PRISIONAL - Pena fixada com critério e corretamente - Reincidência do réu que inviabiliza a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas - Bis in idem não caracterizado, pois o aumento na segunda etapa e a impossibilidade de aplicação do privilégio na terceira fase são efeitos distintos decorrentes do mesmo instituto - Inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, por força do disposto nos artigos 44, incisos I e II, e 77, caput, e inciso I, ambos do CP - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso desprovido." (TJSP - Apelação 0003941-43.2015.8.26.0127 - 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Nelson Fonseca Junior - j. 14/09/2017) -g.n.

Pelos mesmos motivos, fica vedado o direito de o réu apelar em liberdade, pois necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Registro que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o réu está preso há apenas dois meses e dezenove dias, não tendo, ainda, preenchido o requisito objeto para progressão de regime.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu FERNANDO FESSEL a cumprir cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado que a quantia apreendida em poder do acusado é decorrente do tráfico, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Diante da reincidência específica e, considerando a maior gravidade do crime em comento, considerado hediondo, verifica-se maior gravidade da conduta e real possibilidade de reiteração criminosa. Assim, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual fica mantida. Recomende-se o réu na prisão em que ele se encontra recolhido, servindo-se a presente de ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença ora proferida. Pelo RÉU e DEFESA foi dito que DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA da acusação ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data para o MP. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se o necessário.

Recebo o recurso interposto. Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação. Regularize-se o sistema informatizado. Juntadas as razões, vista ao MP para contrarrazões de recurso. Expeça-se guia de recolhimento e internamento provisória, se o caso.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.